

1502698-51.2020.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... em 13/4/2021, DJe 19/4/2021) (Grifei).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (16,8 G DE COCAÍNA E 35,3 G DE MACONHA). FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE LIMITES LEGAIS MÁXIMOS E MÍNIMOS. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTES E ATENUANTES. ART. 61, II, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502698-51.2020.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502698-51.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2322174/2020 - 02º D.P. GUARULHOS, 15404490 - 02º D.P. GUARULHOS, 3844/20/207 - 02º D.P. GUARULHOS, 2322174 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE DE CARVALHO SOBRINHO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

HENRIQUE DE CARVALHO SOBRINHO e JAMMES WESLEY DIANA SOARES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 28 de dezembro de 2020, por volta das 22h30min, na Rua Lucinda Fernandes Carlos, nº 187, Cabuçu, nesta cidade e comarca de Guarulhos, agindo em concurso caracterizado pela unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça e violência, as quantias de R\$ 1.000,00 (um mil reais) e US\$ 27,00 (vinte e sete dólares) em dinheiro, um binóculo, avaliado em R\$ 300,00, ferramentas, avaliadas em R\$ 147,12 e

uma mochila, de propriedade da vítima Khalil Ibrahim Abdul Hadi, com 82 anos de idade (cf. boletim de ocorrência a fls. 17/20, e autos de exibição, apreensão, avaliação e entrega de fls. 21/24) (fls. 102/103).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/93).

A denúncia foi recebida em 12 de janeiro de 2021 (fls. 104/105).

Os réus foram citados (réu Henrique - fls. 123/124 e réu Jammes - fls. 125/126) e apresentaram resposta à acusação, com rol de testemunhas comuns (réu Henrique - fls. 130/135 e réu Jammes - fls. 137/138).

Em 17 de março de 2021, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 144/147).

Em audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento realizada em 07 de junho de 2021, foi ouvida a testemunha comum Jurandir (fls. 297/300).

Em nova audiência de instrução ocorrida no dia 13 de agosto de 2021, foi colhido o depoimento da testemunha comum Danilo Jofre (fls. 334/335).

Na audiência virtual em continuação, realizada em 10 de setembro de 2021, foi colhido o depoimento da vítima, mediante o intérprete do idioma árabe. Em seguida, os réus foram interrogados (fls. 386/290)

Nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, as defesas requereram o aditamento à denúncia para o artigo 180 do Código Penal, bem como a vinda aos autos do laudo de exame de corpo de delito e o relatório médico da vítima. O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se que não havia razão para aditamento da denúncia, posto que íntegros os motivos que ensejaram o oferecimento nos termos expostos (fls. 386/390).

Em alegações finais, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal com a condenação dos réus nos termos propostos na denúncia. No tocante a análise da pena, na primeira fase da dosimetria, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, tendo em vista as consequências e circunstâncias do crime. Na segunda fase, deve incidir a agravante prevista no art. 61, II, alínea "h", do Código Penal e a agravante prevista no artigo 61, II, alínea "j", do diploma penal, pois o crime foi praticado durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do coronavírus. Não há atenuantes. Na terceira fase, deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal. O regime inicial deve ser o fechado, não sendo cabível a substituição da pena por restritiva de direitos. Por fim, requereu a fixação de valor mínimo de indenização em favor das vítimas, considerando-se os prejuízos causados pela infração penal, nos termos do artigo 387, IV, CPP (fls. 387/390).

Após a juntada dos documentos nos autos requeridos pelas defesas, o Ministério Público reiterou as alegações finais apresentadas, acrescentando que o laudo de fls. 438/439 reforça a necessidade de elevação da pena na primeira fase (fl. 443).

A defesa de HENRIQUE DE CARVALHO SOBRINHO requereu a absolvição do acusado por ausência de provas. Subsidiariamente, postulou a desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada (artigo 169, inciso II, do Código Penal) ou para o delito de receptação (artigo 180 do Código Penal). Em caso de eventual aplicação da pena, postulou: o afastamento da majorante do concurso de pessoas; a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e, não sendo possível tal aplicação, requereu seja procedida a aplicação da suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 77 e seguintes do Código Penal. Por fim, no que concerne ao regime inicial de cumprimento da pena, pugnou pela imposição de regime semiaberto e o direito do réu responder o restante do presente processo em liberdade, em atenção ao princípio da presunção de inocência (fls. 451/462).

Por fim, a defesa de JAMMES WESLEY DIANA SOARES postulou a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal e a fixação de regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda corporal, aplicando-se, inclusive, o disposto no art. 387, §2º, do CPP (fls. 480/484).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 17/20), auto de exibição/apreensão (fl. 21), auto de avaliação (fl. 22), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 23/24), auto de reconhecimento de objeto (fl. 25), ficha de pronto atendimento da vítima (fls. 415/416), laudo de lesão corpora da vítima (fls. 438/439), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria é segura e aponta para os acusados, senão vejamos.

Os réus HENRIQUE DE CARVALHO SOBRINHO e JAMMES WESLEY DIANA SOARES, na fase inquisitorial, permaneceram em silêncio (fl. 09 e fl. 10).

O acusado HENRIQUE DE CARVALHO SOBRINHO, em juízo, trabalhava com bicos de reciclagem na época. Negou os fatos. Disse que estava recolhendo recicláveis com Jammes, oportunidade em que indivíduos em fuga passaram por eles e entregaram alguns pertences. Quando o interrogando e Jammes foram ver o que tinha na mochila, os policiais chegaram e os abordaram. O dinheiro estava no bolso da mochila. Não havia nenhum binóculo. Não estavam de bicicleta no dia. Conhece Jammes da rua há alguns anos, pois fazem o uso de drogas juntos. Negou ter confessado os crimes aos policiais.

Em juízo, o réu JAMMES WESLEY DIANA SOARES, na época dos fatos trabalhava como pintor. Negou a prática delitiva. Narrou que ele e Henrique estavam “catando recicláveis” quando pararam para usar drogas. Havia um grande fluxo de veículos e pessoas na rua. Acharam uma bolsinha vermelha no chão e a pegaram. Então, levaram a bolsinha até um bar que estava fechado, para abri-la, pois estava chovendo. Quando foram abrir a bolsinha, viu uma quantia em dinheiro e a Polícia chegou. Usariam o dinheiro para comprar crack. Não viu binóculo nenhum dentro da mochila, apenas o dinheiro e alguns documentos. Não conhecia os policiais e não sabe a razão pela qual eles lhes imputaram a prática delitiva. Indagado, afirmou que viu uma pessoa correndo e dispensando a bolsinha vermelha. Não sabe quantas pessoas eram.

As negativas dos réus, contudo, encontram-se isoladas nos autos, em aberto conflito com a realidade probatória.

A vítima K.I.A.H., na fase inquisitorial, informou que durante a noite dois indivíduos entraram em sua casa pela na sala, após pularem o muro. Eles disseram ao declarante que queriam dinheiro. Um deles passou a agredir o declarante com um objeto no rosto, recolheram seus pertences e valores e saíram da casa. Estimou que os roubadores levaram mil reais e mais 27 dólares. Acredita que vizinhos ligaram para a polícia. Alguns minutos se passaram e os policiais apresentaram seus objetos e valores que localizaram com os autores e o declarante os reconheceu como de sua propriedade. Não possui condições de reconhecer os autores porque estava escuro (fl. 05). Em juízo, afirmou que só viu um assaltante. Ele desligou a luz e então não conseguiu ver mais nada. Contou que levaram dinheiro, que foi recuperado pela Polícia. Foi roubado também um binóculo que não foi devolvido. Durante o dia já tinham praticado outro roubo, no qual levaram uma escada. Não viu os assaltantes, pois estava escuro. Foi agredido pelos roubadores e ficou bastante machucado, com o rosto “preto”. A Polícia estava atrás do ladrão, mas não chamou a Polícia. Mora sozinho. Estava dormindo quando entraram na sua casa. Os ladrões bateram na porta do quarto e pediram para ele abrir, então abriu a porta. Os acusados não tinham arma. Ficou surdo em virtude das agressões. Um dos assaltantes o segurou e o outro lhe bateu. Naquele dia, mais cedo, ladrões já tinham ido até a sua residência e tinham arrombado a porta. Então, a noite a porta já estava arrombada e só a porta do quarto estava fechada. Em audiência, não conseguiu reconhecer os acusados.

As declarações da vítima merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

“(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando

corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo" (Superior Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - data do Julgamento: 09/03/2017 - data da publicação/fonte: DJe 17/03/2017) (Grifei).

"Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem em nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado." (RJTACrim 42/235).

"Prova. Roubo. Palavra da vítima. Eficácia: - Em sede de crime patrimonial, especialmente o roubo, habitualmente cometido às ocultas, a palavra da vítima assume relevante importância no desate da autoria, pois ela não tem qualquer motivo para acusar um inocente" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1132217/2 - data julg.: 04/05/1999 - Relator: Oldemar Azevedo - 14ª Câmara).

"Prova. Roubo. Palavra de vítima idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, que o reconhece com segurança. condenação. necessidade: - é de rigor a condenação pelo delito de roubo na hipótese em que o reconhecimento feito pela vítima é seguro, pois trata-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se podendo imaginar que venha a mentir para acusar um inocente" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1130589/7 - data julg.: 20/04/1999 - Relator: San Juan França - 14ª câmara).

Mas não é só.

Os policiais militares JURANDIR DO NASCIMENTO JUNIOR e DANILO JOFRE, na fase extrajudicial, em depoimentos semelhantes, narraram que receberam a informação via COPOM de roubo em andamento na Rua Lucinda Fernandes Carlos, 187, receberam também as características dos autores, equipe se deslocou ao local e, na Rua Maria Dias Hog, próximo do local do roubo, se depararam com dois indivíduos com características semelhantes àquelas fornecidas via COPOM, ambos em uma bicicleta e estavam na posse de alguns objetos. Durante a abordagem, ambos confessaram o roubo da residência, confessaram inclusive que agrediram fisicamente a vítima. Foi localizada a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais) e 27 dólares com o indivíduo identificado como Jammes Wesley Diana Soares, no bolso de sua calça. O outro indivíduo foi identificado como Henrique de Carvalho Sobrinho, o qual estava com um binóculo da vítima e com ferramentas da vítima. A vítima foi comunicada, o senhor Khalil Ibrahim Abdul Hadi, natural do Líbano, o qual informou que dois indivíduos entraram em sua casa, o agrediram e subtraíram pertences de sua casa. A vítima reconheceu os objetos localizados com os indivíduos bem como os valores como de sua propriedade. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, a vítima foi encaminhada ao UPA Paulista para ser medicado e os indiciados foram trazidos para esta Delegacia de Polícia (fl. 03 e fl. 04).

Em juízo, o policial militar JURANDIR DO NASCIMENTO JUNIOR relatou que receberam informações, via COPOM, a respeito de um roubo em andamento, onde dois indivíduos tinham acabado de praticar o crime a um senhor de idade. Foram repassadas informações a respeito das roupas dos indivíduos. Os réus haviam deixado a bicicleta em um canto, a aproximadamente 40m do local da abordagem. Afirmou que o que chamou a atenção foi a roupa dos réus e a cor de seus bonés. Acha que um dos bonés era branco. Como o roubo havia acabado de ocorrer, foram procurar nas imediações. Acredita que abordaram os réus a quinhentos metros dos fatos. Afirmou, ainda, que no dia estava chovendo, então não havia muitas pessoas na via pública. Durante a abordagem, os réus não reagiram e confessaram o crime. No bolso de um dos réus foi encontrado o dinheiro que foi subtraído da vítima. Na mochila havia ferramentas, como alicates, documentos da vítima e binóculo. Os acusados foram abordados aproximadamente dez minutos após os fatos. A vítima havia sido agredida e apresentava várias lesões. Chegaram a levar a vítima ao hospital. Tratava-se de um senhor de idade, bem debilitado, que foi agredido pelos réus. Na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu os acusados. Contou que a vítima lhes relatou que

estava dormindo e acordou com o barulho que os réus fizeram ao invadir sua residência. Os réus entraram na casa da vítima pulando o muro. Durante a abordagem, os acusados mencionaram que não sabiam que a vítima estava dentro de casa e admitiram tê-la agredido. Afirmou que na data dos fatos os réus estavam diferentes, mais barbudos, e aparentavam ser usuários de entorpecentes. Relatou que em um bar abandonado encontraram o restante dos bens que haviam sido subtraídos pelos réus. O bar ficava a aproximadamente vinte metros do local da abordagem dos réus e foi indicado por eles. Não conhecia os réus anteriormente.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar DANILO JOFRE, o qual, em juízo, relatou que na data dos fatos estavam atendendo uma ocorrência próximo ao local dos fatos, quando foram informados, via COPOM, a respeito da ocorrência de um roubo em residência. Como estavam próximos, se deslocaram ao local dos fatos. Durante o deslocamento, foram informados de que os indivíduos já tinham evadido do local e estavam em local próximo. Foram informados de que um dos sujeitos usava um boné verde e o outro um boné preto. Eles estavam com uma bicicleta. Localizaram os indivíduos e realizaram sua abordagem. Em um primeiro momento, não esboçaram reação e durante a busca pessoal foi encontrada uma quantia em espécie no bolso do Jammes (mil reais e alguns dólares) que, na época, estava usando cavanhaque e vestia uma blusa preta. Indagados a respeito da origem do dinheiro, os réus confessaram o crime. Disseram que entraram na residência para praticar um crime de furto, pois acreditavam que a residência estava vazia. No entanto, na casa havia um senhor de origem estrangeira. Então, agrediram o senhor e se evadiram do local. Deixaram vários objetos próximos a um bar e levaram o dinheiro no bolso. Indagado, afirmou que os réus que lhe contaram que espancaram a vítima. Acredita que eles mencionaram que a vítima tentou reagir. Os réus foram abordados próximos à casa da vítima, aproximadamente 150m. Falou com a vítima de forma bem rápida, pois ela foi socorrida. Indagado a respeito das vestes do acusado, disse que um deles vestia uma camisa da seleção brasileira. Os acusados aparentavam estar lúcidos. Os objetos foram encaminhados para a Delegacia e acredita que posteriormente o proprietário os retirou. Não se recorda se foi realizada perícia no local. A vítima era um senhor de idade, estava bastante machucado e seguiu para a UBS. Não se recorda se a vítima compareceu ao D.P.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que

esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Pois bem, diante das declarações judiciais e extrajudiciais da vítima, acrescida dos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, além do fato dos acusados terem sido abordados, em curto período, em poder dos pertences subtraídos da vítima, forçoso reconhecer que restou demonstrada, à saciedade, a participação de HENRIQUE e JAMMES no delito de roubo apurado nos autos, não sendo caso de absolvição por falta de provas.

A vítima apresentou versões pormenorizadas, coerentes e harmônicas a respeito do crime, tanto na fase policial quanto judicial, não havendo qualquer justificativa para desacreditar na veracidade de tais declarações. Aliás, a vítima confirmou seguramente que foi bastante agredida pelos acusados, que chegaram a bater sua cabeça no chão, de acordo com o laudo pericial de lesão corporal de fls. 438/439, o que afasta as teses de desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada e/ou para o delito de receptação formuladas pela nobre defesa do acusado Henrique.

O fato da vítima não ter conseguido realizar o reconhecimento, não afasta a certeza da participação dos acusados no crime, em razão das circunstâncias da prisão, eis que abordados pouquíssimo tempo após o delito e nas proximidades do local dos fatos, trajando as roupas informadas para a polícia como sendo a dos roubadores, além de estarem em poder dos objetos subtraídos e terem confessando informalmente a prática delitiva, indicando ainda o local em que estavam os demais bens subtraídos.

Nota-se, ainda, que os policiais, ouvidos sob o crivo do contraditório, mostraram-se firmes e seguros ao corroborarem os termos da denúncia, de maneira detalhada, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar tivessem os policiais motivos quaisquer para imputar, falsa e levianamente, a autoria do fato aos acusados, pessoas desconhecidas, com quem não guardam relação.

Por outro lado, as versões dos denunciados, além de contraditórias, não convencem, pois não se coadunam com os demais elementos de convicção coligidos ao longo da instrução criminal, os quais, ao reverso, confirmam os termos da inicial acusatória e evidenciam a responsabilidade criminal de Henrique e Jammes.

Além da certeza da materialidade e da participação dos acusados no crime, com igual precisão, o concurso de agentes restou evidente através da forma de atuação dos réus, agindo em conjunto entre si, ambos com plena aderência de vontades, cada qual fazendo sua a ação do outro, não tendo qualquer deles, em nenhum momento, feito menção a obstaculizar a prática criminosa, o que importa em reconhecer a causa de aumento de pena tipificada no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Seguindo esse entendimento: TACRSP: "Para caracterização da qualificadora do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível" (RJDTACRIM 23/96).

Ainda, nesse tocante, insta frisar que "não apenas aquele que comete ou pratica a ação típica incorre no crime previsto pela norma penal. Esta premissa, enquanto fundamento do concurso de pessoas, decorre justamente da possibilidade de que - pela divisão de tarefas - alguns agentes, apesar de atuarem na atividade ilícita, não realizem nenhum dos núcleos de tipo característicos do injusto culpável". (TJSC - Apelação Criminal n., de Joinville, Rel. Des. Torres Marques, j. em 19/08/2008). O crime se consumou, uma vez que no caso de roubo a consumação se dá com o emprego de violência ou de grave ameaça e a subtração do bem, não sendo necessária a posse mansa e passiva da res furtiva. Nada obstante, no caso dos autos os réus chegaram a ter a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, uma vez que após terem subtraído os objetos do ofendido e fugido do local, a polícia militar foi acionada e, prontamente, em diligências pelas proximidades, conseguiu abordar os acusados com os pertences, o que torna inquestionável a consumação delitiva.

A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido, consagrada

pela Súmula 582 daquela Corte, que consigna: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. O Supremo Tribunal Federal também adota atualmente este entendimento:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de anulação de condenação transitada em julgado. 1. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame de material probatório e não deve funcionar como substitutivo de revisão criminal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída não é necessária para a consumação do delito de roubo. 3. [...] 4. [...] 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega Provimento” (STF Recurso Ordinário em Habeas Corpus rel. Min. Roberto Barroso Primeira Turma - j. 04/02/2014).

Por outro lado, a prática do delito em questão não se mostra, a meu ver, mais grave por ter se dado no contexto de calamidade pública, decorrente da pandemia da Covid-19. Até porque admitir a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, sem a devida motivação, pode levar à indesejável exasperação de todas as penas por todos os delitos cometidos durante a pandemia, o que contraria frontalmente a necessidade de individualização e de adequação da pena ao caso concreto.

É por entender que a incidência da agravante exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para prática do delito, ou seja, que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para cometer o crime, o que, a meu ver, não aconteceu no caso concreto, sendo, portanto, de rigor o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, alínea “j”, do Código Penal.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal requer nexos entre tal circunstância e a conduta do agente, conforme elenca a jurisprudência a seguir:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitativa (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 4/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021.

2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20/3/2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial.

3. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 19/4/2021) (Grifei).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (16,8 G DE COCAÍNA E 35,3 G DE MACONHA). FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE LIMITES LEGAIS

MÁXIMOS E MÍNIMOS. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTES E ATENUANTES. ART. 61, II, J, DO CP. CALAMIDADE PÚBLICA. CONTEXTO DE PANDEMIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. 1. Quando a quantidade ou a variedade da droga não é significativa, não há falar em exasperação da pena-base, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade. 2. A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para prática do delito. 3. O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige que o paciente seja primário e de bons antecedentes, condição essa não preenchida pelo paciente. 4. Ordem parcialmente concedida para redimensionar a pena a 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 530 dias-multa, à razão mínima, pelos fundamentos declinado" (HC 654.255/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021) (Grifei).

Por fim, presente a agravante tipificada no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, eis que incontroverso nos autos que a vítima K.I.A.H. contava com 82 anos de idade na data dos fatos, o que restou evidenciado pela sua qualificação realizada no boletim de ocorrência, durante sua oitiva no inquérito policial, bem como nesta instrução, quando exibiu seu documento.

Convém ressaltar que se trata de agravante de ordem objetiva, de forma que, uma vez demonstrado que a vítima era pessoa idosa, cabível a aplicação da agravante. Ressalte-se, ainda, que no caso dos autos, as características físicas/aparência da vítima constatadas em audiência, cuja imagem ficou gravada em seu depoimento judicial, evidenciam sua idade, deixando claro que os acusados ao cometerem o delito contra o ofendido, tinham ciência de que se tratava de pessoa idosa. Desta feita, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizadas suas culpabilidades, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seus comportamentos, é de rigor a condenação do acusados nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na dosagem das penas, na primeira fase, verifico que os acusados ostentam maus antecedentes, eis que possuem condenações definitivas por fatos anteriores ao apurado nos autos, embora não sejam aptas a gerar reincidência, em razão do trânsito em julgado ser posterior (réu Henrique - processo n.º 1503376-03.2019.8.26.0535, da 6ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução da pena n.º 0021470-65.2021.8.26.0224, da Vara das Execuções Criminais do Foro de Guarulhos, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 492/493, certidão de objeto e pé de fls. 375 e F.A. de fls. 485/488 e réu Jammes - processo n.º 0000323-22.2015.8.26.0570, da 2ª Vara Judicial do Foro de Iguape, conforme certidão de objeto e pé de fls. 376/383). Ademais, não pode este juízo desconsiderar o fato da ação criminosa ter sido praticada com violação de domicílio alheio, ou seja, os denunciados praticaram outro delito como meio para a prática de seus intentos, o que torna a conduta mais reprovável. Ainda assim, a vítima foi gravemente agredida quando já subjugada pelos acusados transbordando o dolo insito ao tipo penal de roubo, inclusive, relatou que, em virtude das agressões, teve vários problemas, como surdez. Dessa feita, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis mencionadas, aplico o aumento da pena-base de 1/3 (um terço), com fundamento no artigo 59 do Código Penal, resultando 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa para cada um dos réus. Na segunda fase da pena, ausentes circunstâncias atenuantes a serem consideradas para os dois acusados. Presente, por outro lado, a agravante tipificada no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, eis que os acusados praticaram o crime

em face de vítima K.I.A.H., a qual contava com 82 anos de idade à época dos fatos e, portanto, era idoso. Assim, acresço as penas em 1/6 (um sexto), fixando-as em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa para cada um dos réus.

Na terceira etapa, ausentes causas de diminuição de pena. Presente, por fim, a causa de aumento do inciso II do §2º do artigo 157 do Código Penal, assim, acresço as penas de 1/3 (um terço), fixando-as, em definitivo, em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa para os réus Henrique e Jammes.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica dos réus, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Em face da quantidade da pena imposta, do fato do delito ter sido praticado mediante grave ameaça e violência a pessoa, além dos réus ostentarem maus antecedentes, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como da concessão do benefício do sursis para os acusados.

O regime inicial para o cumprimento da pena é o FECHADO para os acusados Henrique e Jammes. Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica, não só pela quantidade de pena imposta, mas também pelo fato de que a sociedade, nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, mormente ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticados cada vez de modo mais frio e arrojado, cabendo ao Poder Judiciário coibir os casos que vêm à sua análise, buscando devolver aos cidadãos um mínimo de paz social e ordem pública. Assinale-se que não se considerou apenas a gravidade evidente do crime, mas o modo pelo qual se desenvolveu o ato criminoso, ou seja, roubo praticado em concurso de agente, em face de vítima idosa, que foi violentamente agredida, praticado com violação da residência, asilo inviolável, o que evidencia a alta reprovabilidade da conduta e periculosidade dos acusados, a afastar a aplicação de regime diverso do fechado.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

"Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e da materialidade. Confissão em juízo, ainda que parcial, em sintonia com a prova oral. Reconhecimentos pelas vítimas na polícia. Depoimentos em juízo coerentes e seguros. Condenação de rigor. Qualificadoras bem proclamadas. Pena que já beneficia o réu. Regime fechado necessário. Apelo improvido". (Apelação nº 990.10.361828-9. rel. Des. Pinheiro Franco, 5ª Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010). (grifo do relator).

"Apelação Criminal. Roubo majorado - Absolvição nos termos do art. 386, VI do CPP. Incabível. Provas robustas e suficientes para sustentar o decreto condenatório. Fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Regime inicial fechado é o mais adequado à espécie, e foi fixado nos termos da Lei Apelo não provido". (Apelação nº 90602148620098260000. rel. Des. Sérgio Ribas, 5ª Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010). (grifo do relator).

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento.

No mais, considerando-se a gravidade do delito cometido pelos réus, o fato de terem permanecidos presos durante a instrução criminal, além de ostentarem maus antecedentes, não poderão recorrer em liberdade. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou as prisões preventivas não se alterou. É dizer, os

pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade dos réus subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Ainda assim, diante das condições subjetivas e da quantidade de pena aplicada aos acusados faz submergir a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

No sentido exposto, Julio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: "O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional".

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: "Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social." (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590).

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR HENRIQUE DE CARVALHO SOBRINHO e JAMMES WESLEY DIANA SOARES, qualificados nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, ao cumprimento de 8 (OITO) ANOS, 3 (TRÊS) MESES e 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 20 (VINTE) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

Os acusados Henrique e Jammes não poderão recorrer em liberdade.

Recomendem-se os réus ao local onde estiverem presos.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei. De acordo com a declaração e pedido formulado pela nobre defesa às fls. 122, concedo ao acusado Jammes os benefícios da Justiça Gratuita. Ainda assim, defiro ao acusado HENRIQUE os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Insta consignar que a cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que os acusados têm condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, §3º, do C.P.C.

Outrossim, não é possível fixar um valor mínimo para indenização, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, uma vez que o pedido deveria constar da denúncia, a fim de possibilitar ao acusado se contrapor ao pedido bem como à sua extensão. Desta forma, a ausência de tal pedido no momento do oferecimento da denúncia, mas apenas em sede de alegações finais por parte do Ministério Público, quando já encerrada a instrução, impede a fixação de valor, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa. Sobre isto, aliás, leciona Guilherme de Souza Nucci: "Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa." (Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Editora Forense, 2013, 13ª edição, p. 800).

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação

dos réus, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;

2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação dos réus.

P.I.C.

Guarulhos, 16 de dezembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA